



# 社会组织及其法制化研究

鲍绍坤\*

**内容提要** 社会组织是国家治理体系和治理能力现代化的有机组成部分,是社会治理的重要主体和依托。当前,我国社会组织发展增量较快,但总量仍然偏少且发展比较粗放,整体水平和社会认同度也不高。为培育和促进社会组织健康有序发展、有效参与社会治理,应当采取切实可行的措施,加强党对社会组织的领导;创新和探索社会组织参与社会治理的领域、手段、方式方法;社会组织要积极加强自身建设,在创新社会治理中积极发挥重要作用。应加快社会组织法律法规制定修改完善工作。在法律修改完善过程中,应注意突出以下几方面问题:坚持直接登记和双重管理有机统一;深化社会组织登记制度改革;创设备案制度;完善社会组织法人治理结构;建立科学统一、有机协调的监管机制;完善税收优惠政策。

**关键词** 社会组织 国家治理 社会治理 双重管理 社团登记

社会组织是国家治理体系和治理能力现代化的有机组成部分,是社会治理的重要主体和依托。现代政治学认为,一个成熟的社会,是政府、企业和社会组织三种力量基本均衡的社会。<sup>①</sup>在我国协调推进“四个全面”的战略布局中,各种社会组织承担着越来越重要的时代使命,同时也面临着发展中的各种困境和障碍。在探索中国特色社会主义组织发展道路的进程中,坚持顶层设计和实践探索相促进,坚持积极引导扶持与严格依法管理相结合,切实激发、释放社会组织的内在活力和发展动力,是实现经济社会平稳转型、建立动态和谐现代秩序、推动国家治理体系和治理能力现代化的重要理论与实践课题。

## 一、社会组织的概念及其特征

西方国家社会治理的显著特点之一,就是高度自治化与组织化。各类协会、民间团

\* 中国法学会副会长兼秘书长。

① 参见廖湾、石国亮:《中国社会组织发展管理及改革展望》,载《四川师范大学学报》(社会科学版)2011年第10期。



体、互助组织、教会、基金会、慈善机构等大量社会组织生长和活跃于经济、文化和社会生活之中,发挥着满足社会成员多元化需求,监督政府与市场,增强公民自治精神、主体意识、责任意识等多方面功能。根据西方发达国家的发展经验,只有大量的社会组织参与 to 公共服务和社会治理中,才能有效弥补“政府失灵”“市场失灵”,形成全民共建共享的社会治理格局,从而推动传统政府向现代公共服务型政府转型。然而,在西方国家,社会组织并非一个严格定义的词汇,一般被称为“第三部门”“非营利部门”、“志愿部门”或者“利他的部门”。<sup>②</sup> 总体而言,他们显示的是在官僚体制的政府体系和利润导向的企业部门之外的社会组织的力量。美国约翰·霍普金斯大学的萨拉蒙教授概括了“第三部门”的五个特征:

1. 组织性(formal organization)。即有正规的组织机构和管理制度并开展经常性的活动。那些临时聚集在一起的人群或者经常活动的非正式团体应被排除在外,尽管他们也有很重要的社会功能。同时,第三部门必须具有正式注册的合法身份。具备法人资格才能使第三部门可以对外以法人的身份订立合同,管理者不会因为执行组织的义务而承担财务责任。

2. 非政府性(nongovernmental)。即在组织机构上独立于政府,它不是政府组织的组成部分,不承担政府的职能,其决策层也不是由政府官员控制的董事会。但这并不是说第三部门不能让政府官员参与活动,也不意味着不能接受政府的支持而是说要有自己的独立决策权,不为政府所控制。在这个意义上,将“第三部门”称为“民间组织”、“非政府组织”是很恰当的。

3. 非营利性(nonprofit - distributing)。是指其成立的目的不是为拥有者谋求利润,但这绝不是说它不能产生利润。它可以收费,在某些时候还可能会有盈余,但这种盈余必须为其服务于公众的基本宗旨服务,不能在其所有者或者管理者中进行分配,这是第三部门与以追求利润最大化为目的的营利组织最大的区别。

4. 自治性(self - governing)。即第三部门实行自我管理,自己监控自己的活动。他们有内部的治理秩序,不受制于政府,也不受制于私营企业或者其他非营利组织。

5. 志愿性(voluntary)。指第三部门的活动以志愿为基础,在组织的管理和其他的一些活动中都有不同程度的志愿者参与。当然,这并不是说其成员大部分都是志愿人员,或者其收入全部或者大部分来自志愿者捐款,而是说只要参与是志愿的即可。<sup>③</sup>

就我国法规、规章的用语而言,社会组织的概念经历了“社会团体”、“民办非企业单位”、“民间组织”等诸多称谓变迁。到目前为止,就整体而言,我国法律并没有就“社会组织”给出明确的定义。但依据党的相关政策文件和有关法律法规,我们可以概括我

<sup>②</sup> 社会学家认为,古今中外的任何社会都是由“个人”、“家庭”和“社会组织”三种成分组成的。社会组织首先可以一分为二,即“政府组织”和“非政府组织”,而“非政府组织”又可以进一步分为“营利组织”和“非营利组织”。社会组织是用“排除法”界定的,既不属于政府组织,也不属于营利性组织的那些社会组织,通常被称为“非营利组织”。

<sup>③</sup> 参见吴东民、曹西明主编:《非营利组织管理》,中国人民大学出版社 2003 年版,第 5 页。

国社会组织的主要类别及其涵义。2006年,党的十六届六中全会首次使用“社会组织”一词,要求“健全社会组织,增强服务社会功能”。此后,党的十七大、十八大、十八届三中全会、十八届四中全会均使用“社会组织”概念。2015年,中共中央办公厅印发《关于加强社会组织党的建设工作的意见(试行)》,指出“社会组织主要包括社会团体、民办非企业单位、基金会、社会中介组织以及城乡社区社会组织等”。2016年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》,明确提出“以社会团体、基金会和社会服务机构为主体组成的社会组织,是我国社会主义现代化建设的重要力量”。据此,我们可以将社会组织理解为以社会力量为基础,以公共利益为主要目标,以提供公共服务和从事公益活动为内容的群体和组织形式,包括社会团体、基金会和社会服务机构等三大类。根据2016年2月6日修正的《社会团体登记管理条例》,“社会团体”是指“中国公民自愿组成,为实现会员共同意愿,按照其章程开展活动的非营利性社会组织”。根据1998年10月颁布的《民办非企业单位登记管理暂行条例》,“民办非企业单位”是指“企业事业单位、社会团体和其他社会力量以及公民个人利用非国有资产举办的,从事非营利性社会服务活动的社会组织”。根据2004年2月国务院第39次常务会议讨论通过的《基金会管理条例》,“基金会”是指“利用自然人、法人或者其他组织捐赠的财产,以从事公益事业为目的,按照本条例的规定成立的非营利性法人”。

2016年9月1日,《中华人民共和国慈善法》施行,正式将“民办非企业单位”更名为“社会服务机构”。《慈善法》第8条第2款规定:“慈善组织可以采取基金会、社会团体、社会服务机构等组织形式”,这就意味着“民办非企业单位”概念变更为了“社会服务机构”。之所以这样修改,主要是因为“民办非企业单位”是一个否定式的命名,很容易涵盖基金会、社会团体等其他社会组织,而且不能准确反映这类组织提供社会服务、从事公益事业等特征。同时,过于强调“民办”,不利于官办民营、民办公助、以及推进有条件的事业单位转为社会组织等新的发展趋势相适应。<sup>④</sup>《慈善法》厘清了长期以来名不副实、外延不清的“民办非企业单位”的概念,对于促进我国社会的健康发展,具有十分重要的法律意义。

## 二、当前我国社会组织的发展状况

社会组织是我国国家治理体系和治理能力现代化的有机组成部分,是社会治理的重要主体和依托,是我国社会主义现代化建设的重要力量。改革开放30多年来,我国社会组织的发展大致经过了“复苏发展期”(1978-1989)、“曲折发展期”(1990-2001)、

<sup>④</sup> 国家民管局副局长黄茹就“社会服务机构”问题接受媒体采访,载中国社会组织网:www.chinanpo.gov.cn,最后访问时间:2016年12月15日。

“稳定发展期”(2002-2012),以及从 2013 年本届政府开始的“增速发展期”。党的十八大之后,围绕培育扶持社会组织、激发社会组织活力的顶层制度设计与地方创新实验大幅度展开,社会组织获得了前所未有的发展条件。党的十八届三中全会提出“创新社会治理体制”“激发社会组织活力”,并对社会组织改革发展进行专章部署;十八届四中全会进一步提出“加强社会组织立法,规范和引导各类社会组织健康发展”。2016 年中央办公厅、国务院办公厅《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》首次提出“走出一条具有中国特色的社会组织发展之路”,并明确要求“充分发挥社会组织服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用”,为社会组织发挥正能量提供了广阔空间。当前,我国社会组织呈现迅猛发展态势,截至 2016 年第二季度末,全国依法登记的社会组织达 67 万多个,其中社会团体 32.9 万个,基金会 5038 个,社会服务机构 33.6 万个,遍布教育、文化等 14 个行业领域,在促进经济发展、繁荣社会事业、创新社会治理、扩大对外交往等方面发挥了积极作用。<sup>⑤</sup> 与 1988 年归口民政部登记时的 4446 个相比,社会组织数量增长超过 100 倍,逐渐成为社会治理中的一支新生力量。

社会组织作为社会治理的重要主体,作用主要体现在:

1. 提供公共服务。社会组织是满足多元化需求的社会服务提供者。通过合作外包、协议等方式与政府联合或独立提供公共服务,能够提供多元、人性化、回应性强的服务,在文化教育、福利救济、养老助残、医疗互助、社区团结、环境保护、抗灾扶贫、预防犯罪、弱势群体帮扶等各个方面发挥重要作用,通过形成更加科学、高效的公共服务体系,以满足城乡居民日益增长的基本公共服务需求。

2. 承接部分政府职能。市场化方向的改革下,政府治理改革的关键是政府的职能转变和转移,实现“小政府、大社会”的目标。为此,要建设有限政府,实现政社分开,将部分政府“管不了、管不好”的治理职能交由社会组织承接,实现政府向社会放权,使政府逐步从“越位”“缺位”“错位”中解脱出来,真正“瘦身”。政府集中精力做好顶层设计与规划、政策的宏观调控、履行好政府的监督职能等。

3. 推动协商民主。社会组织是群众利益、意愿和诉求的集合体,能够在第一时间内、大范围获取民众需求信息,并将“碎片化”的信息进行拼接、整合和系统化。社会组织协商民主是国家协商民主体系的重要环节,是需要“重点探索”的协商民主领域。通过平等协商、充分讨论以探求“最大公约数”,能够实现社会组织成员有序的政治参与,提升公共决策的科学化民主化;还有助于培养公民平等公开理性包容的协商精神,凝聚更多共识,促进社会和谐。

4. 化解社会矛盾。面对社会转型深入发展、社会利益分化和公民需求多元的新形势,政府“包揽”公共产品的提供和对社会生活领域治理的传统模式,不仅社会成本巨

⑤ 参见张希敏:《中国依法登记的社会组织已达 67 万个》,载新华网:[http://news.xinhuanet.com/politics/2016-08/30/c\\_129263079.htm](http://news.xinhuanet.com/politics/2016-08/30/c_129263079.htm),最后访问时间:2016 年 12 月 30 日。

大,而且政府由于自身利益、道德风险和强制命令等因素,经常处于社会矛盾的“风口浪尖”。社会组织作为政府和公民之间的桥梁和纽带,能够有效实现政府方针政策“上情下达”和所属群体利益诉求“下情上达”的统一,进行不同群体的利益协调和对话,缓冲政府与社会成员的矛盾,维护社会秩序和社会稳定。

5. 激发社会活力。随着社会结构分化加深,社会流动性加强,人们容易产生归属感缺失、孤独、郁闷、反社会等不良心理。社会组织作为公民实现自我管理和参与社会治理的载体,能够最大限度地调动各方面群众参与的积极性,提升社会的自我组织能力和社会成员全面发展的能力。各类社会组织还可以发挥连接和粘合作用,通过团体的力量帮助个人融入社会,有利于社会核心价值观的形成,提高社会凝聚力,激发社会活力。

总之,社会组织参与社会治理代表着社会治理发展的方向和规律,也是我国政府职能转变和社会治理体制改革的必然趋势。面对公民对社会治理多元化、具体化和细微化的需求,我们必须在治理理念、主体、手段、方式等方面做出改革。此外,改革开放多年来我国在经济社会各方面取得长足发展的同时,公民的自主、自治、自我管理和服务意识等都有了很大提升,这也为我们大力发展、扶持培育社会组织提供了良好条件。

当前,我国社会组织发展增量较快,但总量仍然偏少且发展比较粗放,整体水平和社会认同度也不高。主要体现在以下几个方面:

1. 官办色彩较浓。计划经济时代政府管制思维下,具有“准政府性”的官办社会组织大量存在,对行政权力依赖较深,工作模式、运行机制、工作作风等与政府部门类似,去行政化、机关化任务紧迫;其他“草根”社会组织也受到行政权力的一定干预,自治性、专业性、服务能力和质量都亟待提升。由于过多依赖政府的投入与引导,客观上造成许多社会组织独立性和自主性不强,缺乏对人、财、物的自主支配权,以及自律自治和民主管理能力不足、社会责任感缺失等,从根本上丧失了社会组织的“社会性”。

2. 能力水平不足。长期以来,由于政府部门存在“政府万能”的思维定式,对组织的地位和作用认识不足,没有将社会组织视为社会治理的重要力量和平等的合作伙伴关系加以扶持发展,导致社会组织面临资金不足、人才缺乏、优惠政策不够等问题,在参与社会治理方面也缺乏有效的渠道、平台、机制。大多数社会组织在管理方式上行政色彩浓重,缺乏主动性、创造性和进取精神,没有服务意识,对于政府机构和千变万化的市场经济条件缺乏应变能力。有调查结果显示,在我国各级民政部门登记的社会组织中,作用发挥比较好的只占三分之一左右。

3. 法人治理结构不完善。与国外相对成熟的非营利部门相比,我国一些社会组织缺乏以章程为核心的法人治理结构和治理机制,存在组织机构不健全、内部制度不完善、民主管理不到位,财务管理不透明等问题。有的社会组织董事会结构不合理,董事长与首席执行官两人合一;有的社会组织没有设立监事会等监督机构;有的社会组织缺乏对内部人的制衡和监督机制,内部人成为组织的最大受益者和事实上的决策者;有的

社会组织产权关系不明,导致了一系列的产权归属纷争和资产运作不端行为。<sup>⑥</sup>

4. 缺乏公信力。公信力是社会组织建设最为根本的核心问题,是衡量和评价社会组织建设成效的关键因素。近年来,极少数社会组织爆出丑闻,再次说明社会组织并非净土一块;效率低下、官僚主义、以权谋私、贪污腐败等“志愿失灵”现象依然存在。据有关杂志调查,对中国慈善组织持“信任”态度的受访者占34.7%,持“不信任”态度的占40.3%。<sup>⑦</sup> 国际著名咨询机构麦肯锡公司认为“中国社会并不缺少善心,缺少的是对公益性社会组织的信心”。<sup>⑧</sup> 因此,不少学者认为,“公信力不足是制约我国社会组织健康发展的根本原因”。<sup>⑨</sup>

### 三、培育和促进社会组织健康有序发展、有效参与社会治理的宏观思考

中共中央办公厅、国务院办公厅《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》提出,到2020年,建立健全统一登记、各司其职、协调配合、依法监管的中国特色社会组织管理体制,基本建立政社分开、权责明确、依法自主的社会组织制度,基本形成结构合理、功能完善、竞争有序、诚信自律、充满活力的社会组织发展格局。实现这一发展目标,我们应当在党中央坚强领导下,深化部门、系统间的协调联动,组织动员全社会的力量,不断开创社会组织发展新局面。建议从以下几个方面入手:

1. 采取切实可行的措施,加强党对社会组织的领导。党的领导是社会组织坚持正确政治方向、更好发挥职能作用、实现健康有序发展的坚强保证。中央早在1999年就提出要求,要按照应建尽建的原则,实现民间组织(社会组织)中党的组织和工作全覆盖。但社会组织党建工作是当前党建工作的一块“短板”,存在体系不健全、覆盖不全面、作用发挥不充分等突出问题和难题。建议:一是切实提升各地对于社会组织党建工作重要性的认识。比如,中央党的群团工作会议提出“县级以上群团组织符合条件的要成立党组,并发挥领导核心作用”,但法学会作为群团组织,在省、市、县各级法学会组织建立党组方面的工作推进一直比较慢,原因之一即是各地党委政府的认识和重视程度还不够。二是更多地鼓励地方探索创新、先行先试,并及时总结、推广好的经验做法。如许多地方采取的制定社会组织党组织成立工作指引、建设党建工作示范点、发挥“枢纽型”社会组织引领联系和孵化扶持作用、评选优秀党建服务品牌、党建与业务工作有机融合等有效措施,要深度总结并尽快形成可复制、可推广的经验。三是坚持分类管理、原则性与灵活性结合的工作原则。比如对在职领导干部、离退休领导干部在社会组织

⑥ 参见李炳秀、陈晓春:《内部人控制与非营利组织治理结构探讨》,载《云梦学刊》2005年第2期。

⑦ 参见欧阳海燕:《中国人信用大调查:诚信危机刺痛中国》,载《小康》2011年第8期。

⑧ 王海燕:《公益性社会组织公信力研究》,载《征信》2014年第11期。

⑨ 姚锐敏:《困境与出路:社会组织公信力建设问题研究》,载《中州学刊》2013年第1期。

兼职方面的规定不要简单地“一刀切”,针对政治法律类、宗教类等意识形态色彩较浓的社会组织,采取与其他社会组织区别对待的办法,在领导干部兼职个数、年龄、年限等方面适当放宽条件,只对报酬补贴做出明确具体的限制性规定等,以便于强化党的领导。四是切实加强各级社会组织管理机构建设,明确各级社会组织管理机构的主体责任,探索与治理现代化相适应的社会组织管理体制机制。

2. 创新和探索社会组织参与社会治理的领域、手段、方式方法。各级政府要树立和强化多元合作共治理念,扶持和发挥社会组织在社会治理中的重要主体作用。建议:一是深化公共服务社会化发展。政府要加大职能转移委托力度,制定社会组织承接政府职能目录,拓展领域、创新方式、明确程序,加强资金支持、税收优惠、孵化培植、人才培养,建立完善科学的考核评估机制,扩大向社会组织购买服务的范围和规模;政府自身更多关注公共服务的规划、资金安排和监管,从“划桨者”逐步转型为“掌舵人”。二是推进社会组织有序参与协商民主。各级党委、人大、政府、政协及有关部门要把握突出重点、稳步推进、循序渐进的原则,积极吸纳社会组织参与政治协商、立法协商、政策协商、行业协商、社区协商、专题协商等,并建立健全保障社会组织参与协商民主建设的体制机制,实现协商民主的稳定性和持续性,以及促进协商成果的应用转化。三是强化政社合作的协同治理。现代“善治”理论意味着国家与社会良性互动、协同治理。要支持和引导社会组织协同参与自主治理、公共服务和社会管理,大力培育和发展经济类、公益慈善类、民办非企业单位和城乡社区服务等服务性、公益性、互助性社会组织,积极开展矛盾调处、减贫济困、社区矫正、治安巡逻、法律宣传、心理疏导、环境保护等活动,发挥在社区治理、村务管理、民生服务中的“润滑剂”“缓冲器”和“减压阀”作用,促进社会和谐稳定。同时,通过培育公民的参与意识、奉献意识、集体意识,也有助于社会主义核心价值观的形成与践行。

3. 社会组织要积极加强自身建设,在创新社会治理中积极发挥重要作用。促进社会的健康发展,关键还在于加强社会组织的自身建设。从国外经验看,非营利组织能够积极主动地捕捉社会公益领域的多样化需求,注重创造性地开展服务活动,表现出灵活、敏感、高效的独特优势。日本 NPO 中心认为“社会就像一块布,如果政府是纬,而民间非营利组织是经,纵横交织,这块布才结实”。<sup>⑩</sup> 我国社会组织应当增强“自立意识”,摆脱“等靠要”的思维定式,把目光从行政依赖转到自主发展上来,努力形成自己的独特优势。在这方面,我国传统的群团组织作为党和国家政权组织联系群众的桥梁和纽带,具备政治性、群众性、组织性、专业性等多重属性,应当带头发挥重要作用。以中国法学会为例,近年来,中国法学会在参与创新社会治理方面取得了积极成效。比如,承接政府职能方面,包括开展法治评估、法治宣传、政府重大决策法律风险评估、法

<sup>⑩</sup> 民政部“日本 NPO 法律制度研修代表团”:《日本民间非营利组织:法律框架、制度改革和发展趋势》,载《学会》2016 年第 10 期。

律人才培养等社会管理服务职能;参与基层治理方面,在社区、乡镇、学校、军营、监所广泛建立了“法律诊所”“法律服务站”“法律顾问站”“信访工作站”“调解中心”,积极参与开展法律常识咨询、矛盾纠纷调处、信访积案化解等;普法教育和法治社会建设方面,打造了“百名法学家百场报告会”“青年普法志愿者法治文化基层行活动”等特色品牌,建立了一支数量众多、素质过硬的普法宣传志愿者队伍。此外,中国法学会作为全国性法学社团业务主管单位,通过对法学社团和研究会的政治引领、联系服务、监督管理,在培育、引导相关社会组织发展中发挥着“枢纽”作用。可见,在新的形势下,群团组织主动拓展参与社会治理的广度和深度,对于促进和培育各类社会组织的成长、发展,具有重要的引领和示范作用。

#### 四、加快社会组织法律法规制定修改完善工作

从总体上看,社会组织作用发挥不充分,法制建设相对滞后是一个重要原因。社会各方面普遍认为,相关法律法规的欠缺,已经构成阻碍社会组织健康发展的瓶颈。主要体现在:

1. 门槛过高。培育发展不足、登记门槛过高,一直是制约我国社会组织发展的重要问题。我国法律法规对社会组织的会员人数、财产数额、发起人和拟任负责人资格等方面的限制较多,实际上抬高了社会组织成立的门槛。《社团登记管理条例》第10条规定:“成立社会团体,应当具备下列条件:(一)有50个以上的个人会员或者30个以上的单位会员;个人会员、单位会员混合组成的,会员总数不得少于50个;(二)有规范的名称和相应的组织机构;(三)有固定的住所;(四)有与其业务活动相适应的专职工作人员;(五)有合法的资产和经费来源,全国性的社会团体有10万元以上活动资金,地方性的社会团体和跨行政区域的社会团体有3万元以上活动资金;(六)有独立承担民事责任的能力”。大量社会组织尤其是民间“草根”组织无法满足登记条件,实际上处于不具有合法地位的法律困境之中,也就无法为社会提供更好的服务。基于此,党的十八届三中全会提出:“重点培育和优先发展行业协会商会类、科技类、公益慈善类、城乡社区服务类社会组织,成立时直接依法申请登记”,这就在降低准入门槛、简化登记程序方面迈出了实质性步伐。

2. 限制竞争。《社团登记管理条例》第13条第2款规定:“在同一行政区域内已有业务范围相同或者相似的社会团体,没有必要成立的”,“登记管理机关不予登记”。长期以来,该条款在学术界引起了广泛争议与探讨。但民政部2016年8月发布的《社会团体登记管理条例》(修订草案征求意见稿)第17条第3款规定“申请登记的全国性社会团体与已登记的全国性社会团体业务范围相同或者相似,没有必要成立的”,“登记管理机关不予登记,并向申请人书面说明理由”。这意味着在“一业一会”方面,只对全国性社会团体作出了限制。《社会服务机构登记管理条例》(修订草案征求意见稿)第16



条去除了原有“在同一行政区域内已有业务范围相同或者相似的民办非企业单位,没有必要成立的”,“登记管理机关不予登记,并向申请人书面说明理由”。上述修订草案取消了限制区域内竞争的既有规定,无疑是一种历史的进步。

3. 监管措施不完善。走中国特色社会组织之路,必须坚持放管并重。我国针对社会组织实行“归口登记,双重管理”体制。设计这种体制的初衷,是既要充分发挥登记管理部门的监管责任,又有效发挥业务主管单位的监管积极性。但相关法规缺乏十分明确的权责分工和实施细则,导致出现“二律背反”的“悖论”:登记管理部门由于人员、经费等因素,更多是实施对社会组织的登记注册职责,疏于日常监管;业务主管单位更多侧重对注册前的前置许可,也无暇顾及对社会组织的活动监管,形成注册、管理脱节,重登记,轻服务管理的怪圈,没有很好地营造社会组织良性竞争的制度环境。

4. 缺乏统一的社会组织法。从整体来看,目前我国关于社会组织管理的法律化层次还比较低。我国《宪法》第35条规定:“我国公民享有结社的权利”。《民法通则》第50条规定了“社会团体”法人。在行政法规方面,有《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《基金会管理条例》等三个条例,此外,还有《社会团体分支机构、代表机构登记办法》《社会团体设立专项基金管理机构暂行规定》等若干规章。总体而言,我国社会组织立法的法律位阶不高,彼此之间缺乏有效的相互衔接和内在联系,无法构成一个完善的法律体系。随着社会组织在我国经济社会生活中的地位越来越重要,迫切需要制定统一的《社会组织法》,来具体贯彻《宪法》的有关规定,促进社会组织的健康发展。

加强社会组织建设、激发社会组织活力,必须坚持立法先行,加强顶层设计、统筹协调,尽快形成规范、统一、权威的社会组织法律法规架构,发挥立法的引领、规范和促进作用。建议尽快研究制定统一的社会组织法,明确社会组织的法律地位、主体资格、登记成立、活动原则、经费来源、税收优惠、监督管理、内部自律等基本问题,<sup>①</sup>全面总结我国关于社会组织改革创新的新理念、新思路以及各地实践中的创新做法并加以规范化和制度化,规范和引导社会组织健康发展。加紧修订《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《基金会管理条例》等行政法规,并制定具体的实施办法和相关配套政策,构建社会组织统一监管体系和促进社会组织健康发展的新格局。同时,适应各类社会组织的发展需要,尽快制定行业协会商会法、志愿服务法、社会救助法等专门法律,在法制化轨道上实现分类发展、分类管理。在法律修改完善过程中,应注意突出以下几方面问题:

1. 坚持直接登记和双重管理有机统一。双重管理体制自从20世纪90年代起,就在民间组织、学术界引起广泛争议,不少同志建议取消双重管理制度。也有不少同志认为,由于社会组织种类繁多,性质各异,民政部门目前没有能力对社会组织进行资格审

<sup>①</sup> 参见周红云:《中国社会组织管理体制变革:基于治理与善治的视角》,载《马克思主义与现实》2010年第5期。

查和日常管理,因此需要政府的其他专业部门协助登记机关对社会组织进行管理。因此,双重管理并没有错,错在管理的方式。<sup>⑫</sup> 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》,明确了直接登记和双重管理并存的管理制度。这是适合我国社会组织发展现状的一种现实选择,既体现了简政放权、激发活力的改革方向,又体现了循序渐进、积极稳妥的改革思路。

2. 深化社会组织登记制度改革。简政放权是激发市场活力、调动社会创造力的利器。当前,除行业协会商会类、科技类、公益慈善类、城乡社区服务类四类社会组织直接登记外,还可有序探索扩大服务性、公益性社会组织直接登记的范围。建议民政等部门尽快制定直接登记的社会组织分类标准和具体办法。

3. 创设备案制度。关于如何解决社会组织登记条件过高这一问题,法学界有两种意见:一是降低登记门槛,使一些社会组织取得合法资格。二是创设备案制度,对符合条件的进行登记,对不符合法规规定登记条件、政治上没有问题、有益于社会的社会组织进行备案,给它们一个合法的身份。也就是说,登记和备案都可以成立社会组织,二者的区别在于登记的社会组织取得法人资格,备案的社会组织不取得法人资格。笔者以为,从世界各国的立法情况看,登记与否并不是民间组织合法性的前提条件。美国非营利法人示范法对获得非营利法人资格采取备案制,法国非营利社团法的规定更加宽松自由,其第 2 条规定“社团可以自由设立,而无需核准或者事先宣告,这样的社团不享有法律地位。”如果社团想要拥有特定的法定权利,则必须由其设立人按照属地原则向政府有关部门备案。<sup>⑬</sup> 可见,登记不应该成为一个组织“合法”或者“非法”的分水岭。近年来,各地区积极探索,实行由县(市、区)民政部门统一备案,由街道办事处作为业务主管单位并履行指导监督职责的备案制度,使得大量活跃于社区、为基层群众服务但又暂时不具备法人条件的社区社会组织能够取得合法地位并进入管理视野。<sup>⑭</sup> 从长远来看,通过创设备案制度,从法律上给社会组织提供一个选择成立法人与否的选择机会,是一项富有中国特色的创造性举措。

4. 完善社会组织法人治理结构。健全完善的法人治理结构是社会组织健康发展的前提。民法总则(草案)三审稿对健全社会组织法人治理结构作出了明确规定。“我国民法通则确立的法人种类有机关法人、事业单位法人、社会团体法人、企业法人这几种。随着我国经济社会的发展,民法通则的法人分类方法已经不能满足实践的需要,有必要进行调整完善。民法总则草案按照各类法人设立目的和功能上的不同,将我国的法人区分为营利性法人和非营利法人两大类”。<sup>⑮</sup> 非营利性法人涵盖了事业单位、社会团体、

⑫ 参见康晓光:《权力的转移——转型时期中国社会权力格局的变迁》,浙江人民出版社 1999 年版,第 200 页。

⑬ 参见洪晓梅:《我国非法人型非营利社团的备案制度研究——基于基层民间社团的调查研究》,载《辽宁行政学院学报》2010 年第 8 期。

⑭ 参见前引①,廖鹰文。

⑮ 孙宪忠:《十二届全国人大常委会专题讲座第二十四讲——我国民法典编纂中的几个问题》,载中国人大网 [www.npc.gov.cn](http://www.npc.gov.cn), 最后访问时间:2016 年 12 月 13 日。

基金会、社会服务机构等法人类型。《草案》对健全社会组织内部治理结构作出了明确规定,明确了社会团体非营利性法人、捐助法人,应当设立会员大会(会员代表大会)、理事会、监事会等决策机构、执行机构和监督机构,各种类型的非营利性法人都要依照章程的规定开展活动,这对于促进社会组织法治化建设具有十分重要的意义。社会组织应当依照法律法规规定,建立健全法人治理结构和运行机制,完善会员大会(会员代表大会)、理事会、监事会制度,落实民主选举、民主决策和民主管理,健全内部监督机制,真正成为权责明确、运转协调、制衡有效的法人主体,独立承担法律责任。要建立以章程为核心的内部管理制度,完善章程审核制度,督促社会组织按照章程自我约束。特别要明确社会组织财产权属,在尊重我国传统的民事主体及所有权理论的基础上,区分法人型与非法人型社会组织、公益性与互益性社会组织之间的财产归属差异,合理界定社会组织的财产归属。法人型社会组织存续期间的名下财产归法人自身所有,非法人型社会组织存续区间的名下财产归其设立人单独所有或共同所有;公益性社会团体法人和捐助法人解散时的财产须移交给相同或类似宗旨的其他组织,互益性社会团体法人解散时的财产可分配给团体成员而且允许章程约定归属。<sup>⑩</sup>完善社会组织清算、注销制度,确保社会组织资产不被侵占、私分或者挪用。

5. 建立科学统一、有机协调的监管机制。创新和完善社会组织综合监管体系,明确登记管理机关、行业管理部门及组织、宣传、外事、发展改革、财政、税务、公安、工商等相关职能部门的职责,切实履行各自的监管责任。直接登记不等于放手不管,尤其是降低准入门槛后,要着力克服监管成本高、监管人力不足、各部门之间协调程度低等问题,实现全程和全面监管,双重管理并不意味着排斥和管死,民政部等相关部门对于业务主管单位的监管职责、监管措施要制定更加明确、更具操作性的规定,以便于依法加强监管、处理好违规行为。健全社会组织退出机制。对严重违反国家有关法律法规的社会组织,要依法吊销其登记证书;对弄虚作假骗取登记的社会组织,依法撤销登记;对未经许可擅自以社会组织名义开展活动的非法社会组织,依法予以取缔。引入社会监督,健全社会组织第三方评估机制,建立健全法律监督、政府监督、社会监督、自我监督相结合的综合监管体系,形成监管合力。

6. 完善税收优惠政策。“非营利法人通过主动接受法律的、行政的或者独立机构的监督,获得政府的税收优惠、财政资助、合作契约等特别利益;政府通过实施富有效率的监督手段,可以维护社会公共利益,培育公众对非营利法人的制度信任,最终实现国家与社会的良性互动”。<sup>⑪</sup> 财政补贴和税收优惠,是政府部门支持社会组织发展的主要手段。相对于直接的财政补贴而言,税收优惠政策不会直接控制和干预社会组织的运作,能够在保持社会组织相对独立性的同时,提高财政税收杠杆的运用效果。世界各国普

<sup>⑩</sup> 参见伍治良:《我国非营利组织统一立法的实证调研》,载《法学》2014年第7期。

<sup>⑪</sup> 税兵:《非营利法人解释》,载《法学研究》2007年第5期。

遍注重为社会组织的发展提供税收支持。<sup>⑩</sup> 根据有关学者对 34 个国家的研究,各国政府的财政支持已经达到社会组织总收入的 34%,发达国家达到 48%,而我国政府对社会组织的财税支持还比较有限。中共中央办公厅、国务院办公厅《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》指出:“落实国家对社会组织各项税收优惠政策,符合条件的社会组织按照有关法律法规享受相关税收优惠政策”。建议国家有关部门对不同类型社会组织减免的税种、幅度做出科学界定,实施分类引导;扩大税收优惠的种类和范围,在目前所得税优惠的基础上,还应在财产税、商品税、房产税、车船使用税、城镇使用税等方面给予更多税收优惠。同时,还需要制定合理、规范、高效的税收优惠审批和监管程序。<sup>⑪</sup>

---

**Abstract:** The social organization is not only an organic part of the national governance system and the modernization of governance capacity, but also the important subject and support of social governance. Although the development of social organizations is increasing rapidly at present, the total amount of social organizations is still relatively small and the development of social organizations is too extensive in China. In order to cultivate and promote social organizations to develop orderly and healthily and participate in social governance effectively: certain measures shall be adopted to strengthen the leadership of the party; innovating and exploring the domains, means and methods of social governance; and social organizations shall strengthen their own construction to play an important role in innovating social governance. At the same time, the working concerning establishing and improving laws and regulations of social organizations shall be accelerated, and certain issues shall be paid attention; insisting on the unification between direct registration and dual management; deepening the reform of the registration system of social organization; creating filing system; improving social organization governance structure; establishing a scientific and unified supervision mechanism; and improving preferential tax policy.

---

(责任编辑:李小明)

---

<sup>⑩</sup> 参见袁文艺:《促进社会组织健康发展的税收政策研究》,载中国社会组织网:www.chinanpo.gov.cn,最后访问时间:2015年12月28日。

<sup>⑪</sup> 参见李秀梅:《我国社会组织立法的完善》,载《温州大学学报》(社会科学版)2014年第6期。